

1501323-91.2020.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NELSON GABRIEL COSTA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual NELSON GABRIEL COSTA PEREIRA, maior de 18 e menor de 21 anos de idade na data do fato, foi denunciado como incurso nas penas do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1501323-91.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501323-91.2020.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NELSON GABRIEL COSTA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual NELSON GABRIEL COSTA PEREIRA, maior de 18 e menor de 21 anos de idade na data do fato, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Narrou a denúncia (fls. 54/58) que, no dia 17 de junho de 2020, no período matutino, na Rua da Alegria, n.º 288, São Pedro, nesta cidade e comarca de Osasco, NELSON GABRIEL COSTA PEREIRA, qualificado à fl. 04, maior de 18 e menor de 21 anos de idade, tinha em depósito e guardava drogas, para entrega ao consumo de terceiros, consistentes em 499 (quatrocentos e noventa e nove) porções de cocaína,

com peso líquido de 414,5 gramas, 140 (cento e quarenta) porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 288,5 gramas, e 30 (trinta) frascos com 240 ml (duzentos e quarenta mililitros) de cloreto de metileno/diclorometano, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação às fls. 09/12, auto de exibição e apreensão à fl. 13 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado aos autos.

Segundo o apurado, policiais civis receberam informações sobre as características de um traficante e de um imóvel que era utilizado para o comércio espúrio de entorpecentes. Diante disso, dirigiram-se ao local indicado e lá avistaram o denunciado, o qual apresentava as características informadas, tendo ele, ao notar a presença policial, demonstrado nervosismo, o que ensejou a abordagem.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do increpado, no entanto, ele trazia algumas chaves penduradas em seu pescoço. Indagado se tinha envolvimento com tráfico de drogas, ele, a princípio, negou, mas acabou confessando que, há dois meses, realizava o comércio espúrio de entorpecentes.

Na mesma oportunidade, o denunciado ainda levou os agentes da lei até uma casa próxima e abriu o cadeado com uma das chaves que carregava (vide fotografias às fls. 19/22).

No interior de aludido imóvel, os policiais civis encontraram uma sacola com 499 (quatrocentos e noventa e nove) porções de cocaína e 140 (cento e quarenta) porções de maconha, além de 30 (trinta) frascos contendo cloreto de metileno/diclorometano. Foram, ainda, apreendidos um caderno com manuscritos e 40 embalagens de plástico verde.

Pela grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, associada às circunstâncias de sua apreensão, é certo que se destinavam ao consumo de terceiros.

Laudo de constatação às fls. 09/12.

Auto de exibição e apreensão às fls. 13.

Foi concedido ao acusado o benefício da liberdade provisória cumulado com medidas cautelares diversas da prisão (fls. 42/44), em sede de plantão judiciário. Alvará de soltura cumprido às fls. 161/163.

Às fls. 116 foi aplicado o rito comum ordinário e recebida a denúncia, no dia 23 de novembro de 2021.

Não tendo o réu sido localizado, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional às fls. 123/124.

Posteriormente, no entanto, o réu foi pessoalmente citado, às fls. 133, e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 137/138). Não foi suscitada qualquer questão preliminar e, quanto ao mérito, reservou-se, a Defesa, o direito de se manifestar em momento oportuno.

Às fls. 140/142, este juízo: (i) revogou a suspensão do processo e da prescrição; (ii) manteve o recebimento da denúncia, e (iii) designou audiência de instrução, debates e julgamento.

Folha de antecedentes e certidões de distribuição criminal às fls. 151/153.

Laudos periciais às fls. 169/178.

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação. Foi decretada a

revelia do réu.

Em debates a Acusação pediu a procedência nos termos da inicial.

Em debates a Defesa pediu a improcedência apontando ilegalidades na conduta dos policiais e, por conseguinte, da prova produzida. Em caso de condenação, pena base, redutor, regime aberto e substituição por restritiva.

É relatório.

Fundamento e decido

O pedido é improcedente

A sentença é fundamentada em três argumentos: a) ilegalidade da prova eis que o ingresso em domicílio foi fundamentado em denúncia anônima; b) ilegalidade diante da inexistência de motivo para a abordagem do acusado; c) contrariedade dos depoimentos dos policiais civis.

Com efeito, a finalidade epistêmica do processo penal é a busca da verdade, ainda que de forma aproximada, por meio de reconstrução fática que leve a superação do postulado da presunção de inocência e permita a imposição legítima de uma sanção penal. Entretanto, este objetivo teleológico deve ser buscado com respeito as regras legais e constitucionais de produção e valoração das provas. Não é possível, dentro de um processo penal de fundamento democrático, a valoração da prova dissociada da ideia de legalidade. A legalidade da prova é pressuposto do juízo de mérito. O processo não é um fim em si mesmo e a verdade não pode ser buscada a qualquer custo, ainda mais havendo sacrifício de direito individual. Antes de qualquer valoração racional é sempre necessário o escrutínio da fonte legal da prova.

Nesse sentido: “assim, no Brasil, os códigos processuais, civil e penal, dispõem justamente acerca da validade da prova da verdade, que deverá seguir um trâmite que não cause surpresa às partes (livre acesso), que amplie sua participação no discurso relacionado ao seu enunciado (contraditório), que seja adequada e idônea ao fato que se quer provar e que não seja obtida por meios ilícitos. A busca da verdade não é, assim, orientada para a obtenção da verdade substancial, mas apenas da verdade provavelmente admitida. Não vigora mais, assim, no processo a busca da verdade real. Até porque, como já se disse, não existe essa suposta verdade real. Seria uma pretensão audaciosa do direito entender que o juízo possa fazê-lo unicamente pelos instrumentos legais.” (TAVARES, Juarez, CASARA, Rubens. Prova e verdade. 1ª ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020, p. 147).

O Código de Processo Penal, saliente-se, adotou o sistema do livre convencimento objetivo motivado do juiz, pelo qual incumbe ao magistrado formar sua convicção a partir da livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que fundamentadamente. Em outras palavras, não é lícito ao julgador formar sua convicção e, por conseguinte, proferir sentença condenatória com base em elementos colhidos ao arrepio de direitos individuais. O material probatório levado à análise judicial deve se revestir de legalidade, o que não se verifica no presente caso.

A dinâmica fática relatada pelos policiais, em resumo, consiste no recebimento, por telefone, de uma “denúncia anônima” (não previamente verificada) dando conta de que no local dos fatos uma pessoa guardaria drogas. Foram até o local e localizaram o réu. Com ele nada de ilícito foi encontrado, contudo o réu sponte própria informou o local no qual a droga estaria guarda. O réu teria levado os policiais até a residência, aberto a porta que estava fechada com cadeado e autorizado a entrada, além de informar o local no qual, de fato, a droga estaria.

Pois bem. Extrai-se dos autos que as provas produzidas em juízo têm três fontes: a) denúncia anônima não previamente verificada; b) ingresso em domicílio sem certeza prévia de anuência do morador; c) abordagem sem “fundada suspeita”.

Em primeiro lugar, de rigor salientar que os policiais divergem acerca de como a informação apócrifa, basicamente secreta, teria sido recepcionada. O policial Guilherme aludiu que a informação foi recebida por ele em seu telefone pessoal, o que, não pode e não deve ser, procedimento de polícia judiciária. Já o policial Maurici não se recorda se a informação foi recebida pela delegacia. O certo é que ambos apontam que trabalhavam no 33º DP de São Paulo – substancialmente distante do local dos fatos – e não sabem o motivo pelo qual a ocorrência, do município de Osasco, não foi apresentada em uma delegacia de Osasco. Ainda, a demonstrar o secretismo do comportamento do Estado, não há ordem de serviço ou mesmo relatório da diligência, anotando que as próprias testemunhas afirmaram que quando a diligência é em outro município de rigor a comunicação aos superiores, o que, pelo que se tem dos autos, não fora realizada.

Em segundo lugar, além da total ausência de transparência e controles mínimos quanto a “denúncia anônima”, em seu aspecto formal, no que permite ao aspecto material de conteúdo, os policiais não souberam afirmar, de modo coerente, quais as características que supostamente teriam sido passadas a ensejar a abordagem do réu. Não foi trazida qualquer característica específica, somente características que condizem com mais da metade da população brasileira. O policial Guilherme referiu-se a informações do perfil do “estereótipo” (não se sabe o que isso possa significar) “de uma pessoa que supostamente participaria do tráfico”. Complementou, após pergunta do Ministério Público, que se tratava de “jovem”, “pardo”, “magro”, “sem informação de nome”, mas pessoa que “circulava na região”, que usava “bermuda”, “chinelo” e “camiseta de time”, mas no dia não sabe dizer se a pessoa utilizava camiseta de time. Já o policial Maurici, afirmou que a informação dava conta de “uma casa que havia droga”, o que diametralmente diverge do policial Guilherme. Quanto às características aludiu a “mulato”, “pardo”, “meio forte”, “estatura mediana”, com uma “chave pendurada no pescoço”.

Em terceiro lugar, mesmo sem informações certas (ou aproximadas) da pessoa a ser abordada, houve a abordagem do réu e com ele, afirmam, nada de ilícito fora encontrado. Mesmo assim, afirmam que o réu, em um primeiro momento, teria negado a guarda de drogas, mas, 3 minutos depois, segundo o policial Maurici, confessou que guardava drogas em uma residência e para lá se dirigiu com os policiais, apontando o local no qual a droga estava.

Nessa ordem de ideia, vale sublinhar que denúncia anônima, sem prévia verificação mínima e um nada jurídico se equivalem, notadamente no trato da inviolabilidade domiciliar, onde há de se exigir fundadas razões para excepcionar a regra maior dessa não-violação.

No caso não houve qualquer prévia verificação que pudesse ensejar o ingresso domiciliar. Frise-se que sequer fora investigada a qualificação do acusado ou realizada diligência mínima para aferição da informação. No mais, ainda que a “denúncia” anônima tenha sido recebida por telefone e passada pela chefia, no mínimo espera-se a juntada da “ordem de serviço”, o que não consta dos autos.

Nesse sentido:

Denúncias anônimas não podem embasar, por si sós, medidas invasivas como interceptações telefônicas, buscas e apreensões, e devem ser complementadas por diligências investigativas posteriores. Se há notícia anônima de comércio de drogas ilícitas numa determinada casa, a polícia deve, antes de representar pela expedição de mandado de busca e apreensão, proceder a diligências veladas no intuito de reunir e documentar outras evidências que confirmem, indiciariamente, a notícia. Se

confirmadas, com base nesses novos elementos de informação o juiz deferirá o pedido. Se não confirmadas, não será possível violar o domicílio, sendo a expedição do mandado desautorizada pela ausência de justa causa. O mandado de busca e apreensão expedido exclusivamente com apoio em denúncia anônima é abusivo. (STF. 2ª Turma. HC 180709/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 5/5/2020 Info 976)

Portanto denúncia anônima sem qualquer investigação não pode ser suporte mínimo exigido para a compreensão da exigência de “fundadas razões” – standard probatório necessário para ingresso em qualquer domicílio.

Além do mais, não é crível que o réu tenha de livre e espontânea vontade, já que com ele nada de ilícito foi encontrado, autorizado o ingresso domiciliar. O que se tem, no caso, é evidente coarctação da vontade em virtude do contexto, o que afasta, de plano, qualquer consentimento.

Por outro lado, de fato, mesmo sendo o crime do art. 33 da Lei de Drogas de natureza permanente, especialmente os núcleos típicos ter em depósito e guardar, fixou o Superior Tribunal de Justiça, por meio de atividade interpretativo-teleológica no sentido de trazer conteúdo concreto ao pressuposto legal “fundadas razões” (expressão jurídica indeterminada), no voto condutor do Ministro Rogério Schietti, alguns standard probatórios para validade da prova, dentre eles haver fundadas razões que justifiquem a entrada em domicílio alheio fora as hipóteses constitucionais, que devem ir além da “mera atitude suspeita” ou “fuga do indivíduo em direção a sua casa”. (Habeas Corpus n. 598.051 – SP. Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – 6ª Turma, j. 02.03.2021). Anote-se, por oportuno, que este leading case orientou a unificação do entendimento das duas turmas do Superior Tribunal de Justiça no (Habeas Corpus n. 616.584 – RS – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – 5ª Turma, j. 30.03.2021).

Assim:

(...)

2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação – e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio – justificam o retardo da cessação da prática delitiva.

(...)

4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude “suspeita”, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.

(...)

6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência – uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio – outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio.

(...)

7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com

muita reserva a usual afirmação – como ocorreu no caso ora em julgamento – de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral – pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro – e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.
(...)

Saliente-se, por oportuno, que a questão aqui apreciada já foi objeto de amplo debate na jurisprudência também do STF. O Pleno da Suprema Corte, por maioria de votos, no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616-RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 05/11/2015, fixou a seguinte tese de repercussão geral: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Portanto, a acusação não trouxe provas seguras de anuência do acusado ou de quem de direito para a invasão domiciliar. A prisão, destituída de qualquer mínimo elemento prévio de informação, não é suficiente para a caracterização da legalidade da diligência. Necessários outros elementos de prova como, aliás, já fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobreleva notar que, ainda que não se exija seja a anuência para ingresso domiciliar seja filmada, como afirmado no RE 1342077 – Min. Alexandre de Moraes, é fato que outros elementos de prova devem existir a demonstrar que a autorização foi livre e ausente qualquer tipo de pressão, o que não há nos autos já que o réu estava preso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 12G (DOZE GRAMAS) DE COCAÍNA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA E EM ATITUDE SUSPEITA DOS ACUSADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas – 12g (doze gramas) de cocaína –, quando apoiado em mera denúncia anônima e no fato de que os policiais, de fora, avistaram os acusados no interior da casa manipulando material, não traz contexto fático que justifica a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial, como no caso dos autos. 2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no RECURSO ESPECIAL nº 1.865.363 - SP – 6ª Turma – Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – 22.06.2021).

De mais a mais, além do ingresso domiciliar, a própria abordagem não se justifica tendo em conta a não demonstração de elementos antecedentes que demonstrassem o vínculo do réu com as drogas, repetido que nada de ilícito fora encontrado.

Portanto, no caso em tela, a informação apócrifa teria sido utilizada de modo

ilegal, tanto para a abordagem, quanto para o ingresso domiciliar, sendo que, em ambos os casos, não atende aos standards exigidos pela lei.

De rigor, portanto, o reconhecimento da ilicitude da prova e de todos os elementos que dela decorreram.

Resta, portanto, somente eventual confissão no local dos fatos, anotando que na fase de inquérito o réu manteve-se em silêncio.

Esta confissão – somente no local – não pode ser considerada por este Magistrado. Saliente-se que, se nem a confissão em juízo, como único elemento de prova, pode amparar uma condenação, menos ainda uma confissão no momento da prisão, sem observância de garantias constitucionais, não ratificada, ao menos, perante a autoridade policial.

De fato, a confissão no momento da prisão sem a comprovação de que os agentes policiais garantiram ao réu o direito ao silêncio e o direito a não se autoincriminar é eivada de ilicitude.

Anoto, por oportuno, que eventual confissão no local dos fatos não merece valoração judicial, não apenas porque não há segurança quanto as garantias constitucionais de toda e qualquer pessoa que se vê confrontada com a poder persecutório do Estado – especialmente o direito de não produzir prova contra si próprio –, mas também porque na própria delegacia o réu permaneceu em silêncio, como aludido.

Nesse sentido: STF – AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS N. 170.843/SP – REL. MIN. GILMAR MENDES – 2ª TURMA – J. 04/05/2021). Ou ainda: “Apelação. Comércio ilegal de munição. Sentença procedente. Recurso defensivo. Preliminar. Ilicitude probatória. Violação ao direito a não autoincriminação. Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Desclassificação para o delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003. Aplicação da suspensão condicional do processo. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena no mínimo legal; b) aplicação do regime inicial aberto; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 1. Preliminar. Confissão informal quanto à comercialização ilícita das munições. Violação ao direito ao silêncio. Qualquer pessoa tem o direito de permanecer em silêncio, de não declarar qualquer informação que resulte em auto-incriminação. Art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e art. 8.2.g, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Norma de eficácia imediata, direito que independe de regulamentação por norma infraconstitucional. Necessidade de advertência ao direito ao silêncio em qualquer fase da persecução penal e por qualquer agente estatal. Precedentes da Suprema Corte norteamericana, da Corte Interamericana de Direitos Humanos e dos Tribunais Superiores Pátrios. Inadmissibilidade da prova ilícita. (...)” (TJSP – Apelação Criminal nº 1500308-45.2020.8.26.0556 – 16ª Câmara – Rel. Des. . MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI – j. 1.06.2021).

Por fim, os próprios policiais apresentam incoerências importantes para a reconstrução da verdade, como características do réu, presença ou não de dinheiro, quantidade e qualidade das drogas apreendidas, local de apreensão, distancia do local da abordagem e da casa, enfim, elementos que não permitem um juízo de certeza caso seja superada a questão da legalidade anterior.

O direito penal, frise-se, não se contenta com conjecturas, nem mesmo com probabilidade de autoria. A moderna dogmática penal e processual penal exige a convicção plena do julgador, base ética indeclinável amparada em substrato material valorativo produzido em contraditório. Em outras palavras, a dúvida, por menor que seja, milita sempre em favor do acusado, eis que a presunção de inocência é corolário de um Estado de direito democrático.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e ABSOLVO o acusado NELSON GABRIEL COSTA PEREIRA da acusação de ter infringido o artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Determino a destruição dos entorpecentes apreendidos. Oficie-se.

Osasco, 07 de outubro de 2022.